

1500859-87.2021.8.26.0621

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... não basta, por si só, para configurarem o tráfico, pois é comum o usuário contumaz comprar algumas porções para seu consumo pessoal numa única compra, evitando voltar ao ponto de tráfico mais vezes.

Assim, a versão do réu, considerando os elementos coligidos, é plausível e merece ser prestigiada. Os elementos probatórios e as circunstâncias que cercaram a prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, . - São Roque

CEP: 12570-000 - Aparecida - SP

Telefone: (12) 3105-3352 - E-mail: aparecida2@tjsp.jus.br

1500859-87.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500859-87.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVI GUILHERME DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia DAVI GUILHERME DOS SANTOS, como incurso na prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da LEI Nº 11.343/2006, e artigo 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL, todos na forma do artigo 69, caput, do último CODEx, Narra a denúncia que, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 23:00 horas, Avenida Itaguassu, nº 1.606, SÃO GERALDO, nesta urbe, DAVI GUILHERME DOS SANTOS, qualificado às fls.12, 36, 37/38 e 40/41, e um INDIVÍDUO DESCONHECIDO, em concurso e com unidade de desígnios, previamente ajustados à prática delitiva, subtraíram, para Si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma carteira contendo uma CNH, três cartões bancários e a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, pertencentes a Matheus Silva Forte, e uma carteira contendo uma CARTEIRA DE IDENTIDADE, um CPF, dois cartões bancários e a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em espécie, pertencentes a Alair Sebastião Fortes, conforme autos de reconhecimento pessoal (fls.8 e 10). Consta, ainda, que, logo após, por volta das 23:45 horas, na rua Anchieta, CENTRO, nesta urbe, DAVI GUILHERME DOS SANTOS, qualificado às fls.12, 36, 37/38 e 40/41, em concurso e com unidade de desígnios, previamente ajustados à prática delitiva, com

o menor Dilson Carlos Barbosa, trazia consigo, que outrora adquiriu, para comercialização, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls.19/20), conforme laudo de constatação provisória (fls.24/26).

Apurou-se que, naquela data, o DENUNCIADO aproximou-SE do caminhão das vítimas, bateu no vidro da porta do carona e, com a demora, retirou da cintura um simulacro, anunciando o assalto.

Diante disso, Matheus abriu a porta do motorista e tentou fugir, mas foi impedido por um INDIVÍDUO DESCONHECIDO, baixo, trajando moletom escuro e bermuda verde, O QUAL lhe ordenou que voltasse para o veículo. Ato contínuo, o LIBELADO e SEU COMPARSA surrupiaram as rei furtivae e evadiram-SE numa bicicleta.

Acionados, os policiais militares José Luiz de Oliveira e Silva e Wellington Carlos da Silva, após contato com as vítimas, que lhes informaram as características dos ROUBADORES, iniciaram patrulhamento, tendo, na rua Anchieta, CENTRO, nesta urbe, avistado o LIBELADO e o menor, Dilson Carlos, com os exatos caracteres irradiados. Ao notar a aproximação policial, o LIBELADO arremessou para longe um objeto e o menor tentou fugir, mas foi detido. Abordados e revistados, os milicianos encontraram com DAVI 4 papelotes de cocaína (0,4g) e a quantia de R\$ 7,40, em espécie, e com Dilson 47 papelotes de cocaína (6,62g) e a importância de R\$ 50,00 também em moeda sonante.

Durante buscas no locus, os agentes da lei acharam o objeto arremessado pelo DENUNCIADO, um simulacro de pistola, tendo ESTÚLTIMO confessado a rapina, alegando que teve o auxílio de SEU amigo Felipe.

Interrogado, na DELPOL, DAVI negou, veementemente, as práticas delitivas, informando que apenas acompanhava Felipe Augusto, quem efetivamente praticou o assalto, e que os entorpecentes eram para o SEU consumo pessoal (fls.12). Dilson exerceu seu direito constitucional de permanecer silente (fls.11).

Denúncia recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 120/122).

O acusado ofereceu Defesa Prévia às fls. 101/109, alegando inocência do réu e pedindo sua absolvição sumária com base no princípio In dubio pro reo.

Em audiência de instrução e julgamento foram as ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais de forma oral.

O Ministério Público pediu a parcial procedência da denúncia. Sustentou a presença de materialidade e autoria delitiva no tocante ao crime de roubo. Em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, este não restou configurado, pleiteando a absolvição do réu em relação a este delito. Pediu o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, bem como a fixação do regime fechado para cumprimento de pena. A Defesa, por sua vez, sustentou a ausência de materialidade delitiva no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, bem como o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal, além da fixação de regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fatos tipificados nos artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da LEI N° 11.343/2006, e artigo 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL, todos na forma do artigo 69, caput, deste último CODEX,

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva apenas em relação ao delito de roubo majorado, devendo ser o acusado condenado nos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL. No que tange ao delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput c/c art. 40, VI, da lei n. 11.343/06), anoto não existir prova suficiente da autoria delitiva, operando-se a

desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da mesma lei (posse de drogas para consumo próprio), conforme será abaixo fundamentado.
DO DELITO DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

"Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre quando a posse da coisa é invertida.
"O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima". STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.

Nestes termos, do percuciente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.
A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/07), Termo de Depoimento José Luiz de Oliveira (fls. 08/09), Termo de Depoimento Wellington Carlos da Silva (fl. 10), Termo de Declarações Matheus Silva Fortes (fl. 11), Termo de Declarações Alair Sebastião Fortes (fl. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 18/22), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 23/24), Fotografias (fls. 25/26), Laudo Pericial Objeto (fls. 132/134), bem como pela prova oral colhida.
A autoria restou igualmente demonstrada, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público José Luiz de Oliveira e Silva expôs que:

Estavam em patrulhamento, quando foi irradiado via COPOM uma ocorrência de roubo no bairro de Itaguaçu. Conseguiu contato com a vítima, que passaram as características dos dois indivíduos. Em patrulhamento, conseguiram localizar dois indivíduos de características semelhantes. Os dois tentaram correr. Um deles lançou um objeto ao solo. Com o maior foram encontradas uma pequena quantidade de drogas e dinheiro. Com o menor outras drogas e dinheiro. Conseguiram encontrar o objeto lançado ao solo, que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Em entrevista, o maior confessou a prática do roubo, bem como disse que praticou com uma pessoa chamada Felipe. Disse que levou as carteiras e foram correndo. Não foram recuperados os pertences das vítimas. Foi cerca de 10 (dez) minutos entre a notícia do roubo e o encontro do enunciado. O reconhecimento foi realizado na delegacia. Ele disse que acompanhou o reconhecimento. No ato de reconhecimento foi colocado apenas o redenunciado ao lado do menor de idade., Não havia outras pessoas nesse ato de reconhecimento. Não conhecia o réu anteriormente dos meios policiais, apenas o menor Dilson. O simulacro foi encontrado aproximadamente uns 10, 20 metros do denunciado. Era uma distância pequena.

Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Wellington Carlos da Silva falou que:

No dia da ocorrência, estava na função de motorista da equipe, foi irradiado via rádio uma notícia de roubo. Em contato com as vítimas, foi passada as características dos indivíduos. Em patrulhamento, se depararam com dois indivíduos, sendo que um deles batia com as características. Um dos indivíduos arremessou um objeto ao solo. O outro tentou se evadir, mas os dois foram detidos. Com o menor

foi encontrado uma quantidade de entorpecente e 50 reais em dinheiro. Com o maior, que estava a pé, 4 (quatro) papé debates de cocaína e quantia menor em dinheiro. O maior, em entrevista, confirmou que efetuou o roubo. Encontraram o objeto arremessado, que se tratava um simulacro de pistola. Conduziram todos à delegacia, onde as vítimas reconheceram o maior como sendo autor do roubo e reconheceram o simulacro apreendido como objeto do crime. Narrou não conhecer o réu nos meios policiais. As vítimas não relataram agressão.

Por fim, ainda em juízo, interrogado, o réu DAVI GUILHERME DOS SANTOS alegou que: Os fatos são verdadeiros. Narrou que estava em uma situação de necessidade e por isso praticou o delito em questão. Disse que estava com uma outra pessoa naquele local, mas, por sua segurança, não quis identificar essa pessoa.

Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao crime de roubo (art. 157, CP) diante das provas produzidas.

No presente caso, esgotada a colheita probatória, resta clara a presença de autoria e de materialidade do crime de roubo pelo réu, seja pelas informações obtidas pela vítima em solo policial (elementos de informação), seja pela oitiva das demais testemunhas de acusação, corroborados pela própria confissão do acusado.

Pesa em desfavor do réu o convincente depoimento prestado pelos policiais militares ouvidos em juízo.

O relato dos policiais é coerente, sendo dignos de credibilidade, não havendo nos autos indícios de que este tenha agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidor público que é, muito bem sabe das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 desta Corte (STJ-AgRg 158921/sp – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – j. 10-5-2011)."

No caso, ambos os policiais relataram terem sido chamados para atender ocorrência de roubo e, ao patrulharem próximo ao local dos fatos, visualizaram dois indivíduos, cujas características batiam com as irradiadas e resolveram abordá-los. Neste momento, visualizaram o denunciado dispensando um objeto ao solo. Detidos, com o denunciado foi encontrada uma porção de entorpecente, bem como dinheiro. Com o menor que com ele estava, outras drogas e dinheiro. O objeto dispensado se tratava de um simulacro de arma de fogo, que teria sido empregado contra as vítimas. No mais, o denunciado confessou a prática do delito aos policiais. Relataram, ainda, que as vítimas reconheceram, em solo policial, sem qualquer dúvida, o denunciado como autor do delito patrimonial.

Tal versão é corroborada pelo restante do material probatória colhido aos autos, que dão conta de que os réus efetivaram tentaram subtrair o televisor apreendido nestes autos, tendo empregado violência contra a vítima na tentativa de assegurar detenção da coisa para si.

Cumpra salientar que a oitiva das vítimas foi dispensada pelo Ministério Público, razão pela qual não foi possível obter dela nenhum outro esclarecimento adicional além do seu depoimento prestado em solo policial.

Por tal ocasião, a vítima Matheus de Oliveira Fortes relatou que "estava sentado no banco do motorista de seu caminhão, o qual estava estacionado no local dos fatos. Que, seu pai estava sentado no banco do carona. Que, os vidros das portas estavam fechados. Que, de repente, um rapaz alto, careca, trajando casaco branco se aproximou e bateu com uma das mãos no vidro da porta onde estava seu pai. Que, como demoraram a abrir a porta ele retirou da cintura uma arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta e anunciou o assalto. Que, o declarante abriu a porta do motorista e tentou deixar o local, mas nisso foi abordado por um outro rapaz baixinho, que trajava moleton escuro e bermuda verde que lhe mandou voltar para o caminhão. Que, subtraíram do declarante sua carteira, contendo no seu interior a importância de R\$

200,00 em dinheiro, sua Carteira de Habilitação e três cartões bancários, um do Itaú, um da Caixa Econômica e um cartão cidadão; que, do seu genitor foi também subtraído a carteira, a qual tinha no seu interior a importância de R\$ 350,00, a Carteira de Identidade, o CPF; e, dois cartões bancários, um do Banrisul e outro do Banco do Brasil. Que, após o roubo os ladrões se evadiram numa bicicleta de características não anotadas que haviam deixado atrás do caminhão. Que, algum tempo depois foram informados de que a polícia militar havia prendido dois rapazes suspeitos do roubo e, aqui tendo comparecido, reconheceram apenas um deles, ou seja, Davi Guilherme dos Santos, como sendo um dos autores do roubo. Que, nenhum pertence, nem do declarante e nem de seu genitor foi recuperado. N" (fl. 11). A vítima Alair Fortes declarou em solo policial que: estava sentado no banco do carona de seu caminhão, o qual estava estacionado no local dos fatos. Que, seu filho Matheus estava sentado no banco do motorista. Que, os vidros das portas estavam fechados. Que, de repente, um rapaz alto, careca, trajando casaco branco se aproximou e bateu com uma das mãos no vidro da porta onde estava o declarante. Que, como demoraram a abrir a porta ele retirou da cintura uma arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta e anunciou o assalto. Que, seu filho abriu a porta do motorista e tentou deixar o local, mas nisso foi abordado por um outro rapaz baixinho, que trajava moleton escuro e bermuda verde que o mandou voltar para o caminhão. Que, subtraíram de seu filho sua carteira, contendo no seu interior a importância de R\$ 200,00 em dinheiro, sua Carteira de Habilitação e três cartões bancários, um do Itaú, um da Caixa Econômica e um cartão cidadão; sendo que do declarante também foi subtraído a carteira, a qual tinha no seu interior a importância de R\$ 350,00, a Carteira de Identidade, o CPF; e, dois cartões bancários, um do Banrisul e outro do Banco do Brasil. Que, após o roubo os ladrões se evadiram numa bicicleta de características não anotadas que haviam deixado atrás do caminhão. Que, algum tempo depois foram informados de que a polícia militar havia prendido dois rapazes suspeitos do roubo e, aqui tendo comparecido, reconheceram apenas um deles, ou seja, Davi Guilherme dos Santos, como sendo um dos autores do roubo. Que, nenhum pertence, nem do declarante e nem de seu filho foi recuperado." (fl. 13)

Cumpra salientar que, a despeito de se tratar de elemento de informação (e não prova propriamente de prova judicial), portanto, incapaz de sustentar, por si só, um decreto condenatório, é entendimento já consagrado na jurisprudência que os elementos de informação podem ser utilizados na formação da convicção do juízo, desde que seja amparado pelas demais provas (em contraditório) produzidas nos autos, o que é exatamente o caso, haja vista que o depoimento das testemunhas corrobora toda a versão apresentada pela vítima em sede policial.

Elementos de informação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa. Apesar de não serem produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, tais elementos de informação são de vital importância para a persecução penal.

De seu turno, a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla defesa.

CPP, Art.155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Tendo em conta que esses elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, deduz-se que o inquérito policial tem valor probatório relativo. Questiona-se, então, acerca da possibilidade de sua utilização para formar a convicção do juiz em sede processual.

Como já se manifestou o STF, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios que passam pelo crivo do contraditório em juízo.

A Lei nº 11.690/08, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155, caput, do CPP acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo.

Tanto é verdade que a nova lei não previu a exclusão física do inquérito policial dos autos do processo (CPP, art. 12).

Dessa forma, é plenamente possível que os elementos de informação produzidos em sede de investigação preliminar sejam utilizados pelo juiz na formação de sua convicção, desde que somados a outras provas produzidas em contraditório. Ou seja, o juiz não pode basear sua decisão exclusivamente em sede de elementos informativos.

No caso todos os elementos levam à convicção de ser inconteste, portanto, a autoria delitiva por parte dos réus.

As provas colhidas ao longo da instrução não deixam qualquer dúvida ter sido o autor da infração penal a qual lhe está sendo imputada.

EMENDATIO LIBELLI

Dispõe o art. 383, do Código de Processo Penal:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

No caso dos autos, a descrição de fato contida na denúncia indica que o réu cometeu o delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) por duas vezes (2x) não se tratando de crime único, consoante denunciado.

Isto porque, conforme bem se observa da denúncia e dos documentos que a instruem, o denunciado praticou a conduta contra duas vítimas distintas (Matheus e Alair), resultando na subtração de patrimônio de cada uma delas.

Em situações tais, a jurisprudência está sedimentada pela ocorrência de delitos distintos, ainda que se trate de uma única conduta. Vejamos o acórdão elucidativo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Como os delitos foram cometidos mediante uma única conduta, trata-se de concurso formal, na forma do disposto no art. 70 do Código Penal.

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Em relação ao concurso formal perfeito ou próprio, o Código Penal acolheu o sistema da exasperação.

Aplica-se a pena de qualquer dos crimes, se idênticos, ou então a mais grave, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. O critério que norteia o juiz para fixar o aumento da pena entre os patamares legalmente previstos é, exclusivamente, o número de crimes cometidos pelo agente.

Em se tratando de 2 (dois) delitos, a pena será aumentada no menor patamar legal de 1/6.

A causa de aumento do concurso de agentes ficou devidamente comprovada. Consoante o extenso material probatório produzido ao longo da instrução, especialmente pelo depoimento preciso e seguro das testemunhas ouvidas em juízo que afirmaram que o crime fora praticado pelo denunciado, em concurso com uma segunda pessoa que não foi identificada. Além disso, o próprio denunciado confessou que praticou o delito

em concurso com terceira pessoa, a qual não quis identificar.

Cumprе salientar que a jurisprudência é firme no sentido da caracterização da majorante do concurso de agentes não exige a identificação do corréu. É suficiente a indicação da participação de uma ou mais pessoas na execução do crime.

Não havendo dúvida de que o acusado agiu em concurso e previamente ajustados com um comparsa, estando presente o liame subjetivo entre os agentes, presente está a majorante prevista no p. 2, II, do art. 157, do CP. Não havendo maiores elementos para fixação em maior patamar, será fixada no menor patamar legal de 1/3.

Conforme se observa do boletim de ocorrência alusivo aos autos (fls. 18/22), a vítima Alair Sebastião Fortes possuía mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos, razão pela qual incide a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal.

DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06

Do percuciente análise do acervo probatório, a solução que se impõe é a condenação do réu apenas pelo delito de porte ilegal de entorpecente para uso próprio, pois não há prova segura e cabal de que as pequenas porções de entorpecentes que o réu trazia consigo destinavam-se realmente ao comércio ilícito de entorpecentes, devendo vigorar, no caso, o princípio do in dubio pro reo.

Com efeito, o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer a finalidade da mercancia.

Inicialmente, cumpre frisar que uma sentença condenatória exige prova segura, cabal e estreme de dúvida, pois o Direito Penal não opera conjecturas, razão pela qual sem a certeza total da autoria e da culpabilidade, não se pode proferir um decreto condenatório.

Assim, ainda que parem alguns indícios, estes não são veementes e excludentes da versão ofertada pelo acusado em seu interrogatório judicial.

O réu DAVI GUILHERME, interrogado em juízo, nega a prática do crime. Disse que realmente estava em posse das drogas encontradas, contudo, eram destinadas a seu consumo.

Assim sendo, negou, veementemente, estar traficando drogas no local.

Além disso, os depoimentos das testemunhas não deixam claro que o entorpecente apreendido em poder do acusado se destinava ao comércio espúrio.

Não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico.

Porém, diante do conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de ser o réu é traficante e estar vendendo drogas no local antes da abordagem.

De fato, a prova dos autos não se mostra segura o bastante para apontar o réu como traficante, sendo impossível afastar a sua versão exculpatória, no sentido de que é mero usuário, até porque nem sequer foi apreendida quantia de dinheiro, trazendo pequenas quantias de entorpecentes consigo, para consumo próprio. Aliás, a quantidade de entorpecentes apreendidos não se mostrou elevada; pelo contrário, é bem pequena e compatível com aquelas portadas por usuários.

Além disso, o fato de estar distribuída em porções individualizadas não basta, por si só, para configurarem o tráfico, pois é comum o usuário contumaz comprar algumas porções para seu consumo pessoal numa única compra, evitando voltar ao ponto de tráfico mais vezes.

Assim, a versão do réu, considerando os elementos coligidos, é plausível e merece ser prestigiada. Os elementos probatórios e as circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante não são suficientes para comprovar, seguramente, a finalidade da traficância.

Neste contexto, a isolada apreensão de poucas drogas no bolso do acusado não conduz à conclusão de que são elas destinadas ao comércio ilícito.

Neste contexto, não se pode descartar a veracidade da versão ofertada pelo acusado, hipótese a ele favorável.

Frise-se, novamente, que no processo criminal o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o

acusado o autor do fato criminoso.

Por isso, já se decidiu que: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Enfim, o suporte da acusação enseja razoável dúvida quanto à efetiva participação do réu no crime de tráfico ilícito de drogas, não restando seguramente provado ser ele traficante, nem que a pequena quantidade de drogas que trazia consigo se destinava ao consumo de terceiros.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendida não se mostrou elevada a ponto de afastar a possibilidade deles se destinarem realmente ao consumo próprio do acusado.

Sendo assim, ausente a prova segura da finalidade do tráfico, impõe-se a sua condenação pelo delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, operando-se a desclassificação. Portanto, verifica-se que o quadro probatório não é suficientemente seguro no que se refere à comprovação da finalidade da traficância. Deste modo, havendo dúvida quanto à natureza do fato, se para fins de tráfico ou uso próprio, resolve-se esta em favor do agente, aceitando-se a alegação do uso pessoal da droga. Enfim, no tocante à finalidade da droga, diante da fragilidade do conjunto probatório e se considerando os parâmetros previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para efeito de caracterização dos crimes nela previstos, a solução que se impõe, neste caso em especial, é a desclassificação da conduta do réu para o tipo do art. 28 da citada lei.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Sendo certa a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal (2x) e art. 28, da lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena, a qual faço na forma trifásica, estabelecida pelo art. 68, do Código Penal.

Dosimetria

Delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal: o acusado é primário e não porta maus antecedentes. Merece valoração negativa as circunstâncias em que praticado o delito, vez que o acusado praticou o fato criminoso em período noturno, o que proporciona menor vigilância e aumenta a sensação de insegurança. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são normais à espécie de delito. Assim, lhe é desfavorável UMA circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal (circunstâncias do delito), autorizando a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal (um sexto para cada circunstância). Deste modo, fixo-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos delitos de roubo.

Na fase intermediária, presente a circunstância agravante prevista no art. 62, II, h, do Código Penal, tendo em vista o crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, todavia, o réu confessou o delito imputado, incidindo a atenuante de pena prevista no art, 65, III, d, do CP. Dessa forma, promovo a compensação entre as circunstâncias, mantendo-se a pena no patamar já fixado de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos delitos de roubo.

Na terceira e derradeira fase, presente a majorante prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, qual seja, o concurso de pessoas. Tendo a referida causa de aumento fixada no mínimo legal de 1/3, a pena fica aumentada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Além disso, considerando que foram dois delitos praticados em concurso formal, a pena deve ser aumentada em 1/6. Dessa forma, fica a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Ausente qualquer elemento a respeito da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa no patamar mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Apesar de primário, existem circunstâncias judiciais que pesam em desfavor do réu, notadamente as circunstâncias do crime, bem como por se tratar de delito praticado com grave ameaça à pessoa. Dessa forma, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena corporal, em observância ao disposto no parágrafo terceiro, do artigo 33 do Código Penal, mais compatível com suas condições pessoais.

Praticado o delito com grave ameaça contra a pessoa, inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, do CP.

Da mesma forma, pelo montante de pena aplicada, incabível a suspensão da pena.

DO DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (art. 28 da lei n. 11.343/2006).

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, verifico que ser o réu contar com maus antecedentes depurados. Todavia, desclassificada a conduta, e tendo o réu assumido a posse das drogas, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, que serve para neutralizar e compensar aquela agravante. Assim sendo, e atento às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1(um) mês, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/2006. Inexistindo outras circunstâncias que pudessem interferir na dosimetria, torno-a definitiva no patamar acima

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DAVI GUILHERME DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no menor valor unitário, pela prática do delito definido no art. 157, §2º, II, por duas vezes, em concurso formal (art. 70), do Código Penal, além da pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, pelo delito tipificado no art. 28, da lei 11.343/06.

O condenado respondeu ao processo em custódia cautelar. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade, e presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato do réu ser portador de maus antecedentes, além das circunstâncias e consequências do crime terem extrapolado ao considerado "comum" para essa espécie de delito, tudo a indicar uma maior periculosidade por parte do réu, circunstâncias essas que denotam alta probabilidade de que o condenado, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal e voltará a prática delitiva.

Oficie-se, recomendando-se o réu onde se encontra recolhido.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar,

manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do

Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos

Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida,

tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15,

inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente,

observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017. Em se tratando de réu preso

preventivamente pelo juízo da condenação, no momento da expedição da guia de

recolhimento definitiva deverá a Serventia atentar para eventual termo final de

cumprimento da pena, em atendimento ao Comunicado CG nº 2651/2017, e em caso de

possível cumprimento, deverão os autos virem imediatamente conclusos para expedição

de alvará de soltura antes da remessa ao juízo da execução penal.

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA